

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1052/2545

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี  
นายไพรินทร์หรือต้อย วรพิสุทธีวงศ์ กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายซึ่งกันและกันและกระสุนปืนที่จำเลยที่ 2 ยังไม่ถูกจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายแก่กายอย่างไร และทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนดีสีรัชะของจำเลยที่ 1 จนได้รับอันตรายแก่กายโดยไม่มีเจตนาฆ่าแต่การกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นรวมการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายด้วย และเป็นความผิดได้ในตัวเองดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนสั้นขนาด 6.35 มิลลิเมตร หมายเลขทะเบียน มก.6/16124 จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืน 6 นัด อาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของนายยุทธพล พงษ์พันธ์ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากนายทะเบียน ไว้ในครอบครองของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ส่วนจำเลยที่ 2 มี

อาวุธปืนสั้นขนาด 9 มิลลิเมตรจำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาดเดียวกันไม่ทราบจำนวนแน่ชัดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และจำเลยทั้งสองพาอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในโปโลซิติดีสโก้เชค ซึ่งเป็นร้านอาหารและสถานบริการสาธารณะอยู่ในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่ใช้กรณีที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ จากนั้นจำเลยทั้งสองต่างใช้อาวุธปืนที่ตนมีและพาไปดังกล่าวยิงโดยใช้เหตุในร้านอาหารและสถานบริการโปโลซิติดีสโก้เชคซึ่งเป็นที่ชุมชนและอยู่ในเมืองคนละนัด และจำเลยทั้งสองต่างใช้อาวุธปืนที่ตนมีไว้ในครอบครองและพาติดตัวดังกล่าวยิงทำร้ายซึ่งกันและกันโดยมีเจตนาฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง กระสุนปืนที่จำเลยที่ 1 ยิงถูกบริเวณท้องจำเลยที่ 2 และพลาดไปถูกนางสาวภัสรา กาญจนถาวรวิบูลย์ ผู้เสียหายที่บริเวณทรวงอกด้านซ้าย และกระสุนปืนที่จำเลยคนใดคนหนึ่งยิงพลาดไปถูกสิบโทวันเผด็จ บัวคล้าย ผู้เสียหาย ที่เขาด้านซ้าย จำเลยทั้งสองลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล เนื่องจากจำเลยที่ 2นางสาวภัสรา และสิบโทวันเผด็จได้รับการรักษาจากแพทย์ทันต่วงที่จึงไม่ถึงแก่ความตายและกระสุนปืนที่จำเลยที่ 2 ยิงไม่ถูกจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 60, 371, 376, 91, 33, 32 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ริบปลอกกระสุนปืนขนาด 6.35 มิลลิเมตรจำนวน 3 ปลอก กระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 ปลอก ชองพกหนึ่งขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชอง หัวกระสุนปืน 1 หัว และคืนอาวุธปืนพกสั้นหมายเลขทะเบียน มก/6/16124 แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 288 ประกอบมาตรา 80, 60 อีกสองบทซึ่งมีอัตราโทษเท่ากัน จึงลงโทษเพียงบทเดียว มาตรา 371, 376 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 371, 376 และจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฐานยิงปืนในที่ชุมนุมชนโดยใช่เหตุเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 15 ปี ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น จำคุกคนละ 6 เดือนฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมายลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 15 ปี 12 เดือน ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 10 ปี 8 เดือน ริมปลอกกระสุนปืนขนาด 6.35 มิลลิเมตร 3 ปลอก ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร 1 ปลอก ของพกหนึ่งและหัวกระสุนปืนของกลาง และคืนอาวุธปืนหมายเลขทะเบียน มก.6/16124 แก่เจ้าของข้อหาอื่นให้ยก

## จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 12 ปี รวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น และฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมายเป็นจำคุกคนละ 12 ปี 12 เดือน ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีสำหรับจำเลยที่ 1 เป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 และข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุจำเลยทั้งสองได้ต่อสู้กันโดยจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนสั้นขนาด 6.35 มิลลิเมตร ยิงพยายามฆ่าจำเลยที่ 2 คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น และฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้จำคุกจำเลยที่ 2 แต่ละกระทางไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ไม่ได้กระทำความผิดดังกล่าว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคงมีปัญหาค่าที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและยิงปืนในที่ชุมนุมชนโดยใช่เหตุหรือไม่โจทก์มีนายยุทธพล พงษ์พันธ์ กับนางสาวภัสรา กาญจนถาวรวิบูลย์เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นจำเลยที่ 1 มีปากเสียงทะเลาะกับพวกของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ซึ่งนั่งอยู่กับพวกจึงลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วชักอาวุธปืนสั้นออกจากเอวของจำเลยที่ 2 ใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะของจำเลยที่ 1 จนกระทั่งจำเลยที่ 1 ทరుกลงจำเลยที่ 2 เล็งปืนไปทางจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงพุ่งเข้าไปใส่จำเลยที่ 2 โดยจับมือข้างที่จำเลยที่ 2 ถืออาวุธปืนไว้แล้ว มีการแย่งอาวุธปืนกัน และมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้กอดปล้ำต่อสู้กันและได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันอีก 2 ถึง 3 นัด หลังเกิดเหตุปรากฏว่ามีนางสาวภัสรา สิบโทวันเพ็ญ บัวคล้าย และจำเลยที่ 2 ถูกกระสุนปืนได้รับอันตรายแก่กาย ตรวจที่เกิดเหตุแล้วพบปลอกกระสุนปืนขนาด 6.35 มิลลิเมตร จำนวน 3 ปลอก ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 ปลอก และหัวกระสุนปืน 1 นัด เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองแม้จะเป็นเพื่อนของจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่พยานทั้งสองก็ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 2 มาก่อน อีกทั้งคำเบิกความของพยานทั้งสองน่าจะเป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 1 ด้วยและเมื่อ

พิจารณาประกอบกับคำเบิกความของร้อยเอกเจ็พพร วิปุลัมภ์พยานจำเลยที่ 1 ซึ่งเบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนสั้นดีสีีระของจำเลยที่ 1 จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความไปตามความเป็นจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกของจำเลยที่ 2 ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน จำเลยที่ 2 เข้าไปใช้อาวุธปืนสั้นดีสีีระของจำเลยที่ 1 ทรุดลงแล้วเล็งปืนไปที่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงเข้าแย่งอาวุธปืนจากจำเลยที่ 2 อาวุธปืนของจำเลยที่ 2 จึงลั่นขึ้น 1 นัด แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้กอดปล้ำต่อสู้กัน จึงมีเสียงปืนดังขึ้นอีก 3 นัด ซึ่งจากทางนำสืบของโจทก์ไม่มีพยานโจทก์คนใดเห็นจำเลยที่ 2 ยิงปืนไปทางจำเลยที่ 1 วิธีกระสุนปืนของจำเลยที่ 2 ไม่มีผู้ใดทราบว่าจะพุ่งไปทิศทางใด ทั้งได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นได้ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 เพียง 1 ปลอก ดังนั้น อาวุธปืนของจำเลยที่ 2 จึงอาจลั่นขึ้นเพราะจำเลยที่ 1 และที่ 2 กอดปล้ำแย่งอาวุธปืนกันก็เป็นได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ตั้งแต่แรกที่มีโอกาสยิงจำเลยที่ 1 ได้ในทันทีแต่หาได้กระทำไม่ คงเพียงแต่ใช้ด้ามปืนดีสีีระของจำเลยที่ 1 จะได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามใบความเห็นแพทย์ เอกสารหมายเลข 3 เท่านั้น การที่จำเลยที่ 2 เล็งปืนไปที่จำเลยที่ 1 โดยยังไม่ได้ยิงก็อาจเป็นเพียงข่มขู่เท่านั้น ไม่อาจสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 2 ได้ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงและมีเจตนาฆ่าจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและยิงปืนในที่ชุมนุมชนโดยใช่เหตุ คงฟังได้แต่เพียงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 1 จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเท่านั้นซึ่งศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานพยายามฆ่า โดยใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายซึ่งกันและกันและกระสุนปืนที่จำเลยที่ 2 ยิงไม่ถูกจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายแก่กายอย่างไร และทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนดีสีีระของจำเลยที่ 1 จนได้รับอันตรายแก่กาย แต่การกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น

รวมการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายด้วย และเป็นความผิดได้ในตัวเองดังนี้ ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าขณะเกิดเหตุในบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีแสงสว่างพอที่พยานจะเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนนั้น เห็นว่า พยานโจทก์รวมทั้งพยาน จำเลยที่ 1 ต่างเบิกความว่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 5 ถึง 7 เมตร และ พยานเบิกความได้สอดคล้องต้องกันในสาระสำคัญแห่งคดีจึงน่าจะเชื่อว่าพยานโจทก์ สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน พยานหลักฐานจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยาน หลักฐานโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้นเป็นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 วางโทษจำคุก 2 ปี เมื่อรวมกับโทษความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาจำคุก 12 เดือน แล้ว รวมจำคุกมีกำหนด 2 ปี 12 เดือน ยกฟ้องข้อหาพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 80 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(มงคล ทับเตี้ย-วิเทพ ศิริพากย์-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 พยายามฆ่าจำเลยที่ 1 โดยใช้อาวุธปืนยิงแต่กระสุนปืนไม่ถูกจำเลยที่ 1 แต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาฆ่า จำเลยที่ 1 คงมีแต่เจตนาทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธปืนตีศีรษะจำเลยจนได้รับอันตรายแก่กาย มีปัญหาว่าศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น แต่มีข้อยกเว้นในวรรคท้ายว่าถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 เป็นความผิดที่รวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย อันได้แก่ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามมาตรา 290(คำพิพากษาฎีกาที่ 1329/2536) ความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295(คำพิพากษาฎีกาที่ 136/2536)ความผิดฐานทำร้ายร่างกายสาหัสตามมาตรา 297(คำพิพากษาฎีกาที่ 1592/2534) ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดดังกล่าวที่พิจารณาได้ความได้ แต่ความสำคัญยังอยู่ที่คำฟ้องหรือการบรรยายฟ้องด้วย หากในคำฟ้องมิได้กล่าวถึงการกระทำอันเป็นองค์ประกอบของความผิดดังกล่าวไว้ในฟ้อง ศาลย่อมจะพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวมาในฟ้องนั้นไม่ได้ดังนั้น ถ้าคำฟ้องมิได้กล่าวว่าจำเลยได้กระทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสอย่างไรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 297 วรรคสอง ศาลคงลงโทษได้เพียงฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295 เท่านั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 1450/2529)

คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 1 มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนตีศีรษะจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 ก็ใช้อาวุธปืนดังกล่าวในการกระทำความผิดนั่นเอง คงแตกต่างเพียงว่าใช้อาวุธปืนยิงหรือตีจำเลยที่ 1 อันเป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประทุษร้าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2768/2536, 1351/2539) และศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ยังวางหลักว่า การกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นรวมการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายด้วยและเป็นความผิดในตัวเอง แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายแก่กายอย่างไรก็ตาม ศาลก็ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานทำร้ายร่างกายได้ ซึ่งน่าจะเป็นบรรทัดฐานเฉพาะกรณีที่ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายเท่านั้นไม่รวมถึงฐานทำร้ายร่างกายสาหัสด้วย ไพโรจน์ วายุภาพ